

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0080371-39.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **WALDINEY FARIAS DA COSTA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Edison Tetsuzo Namba****VISTOS**

WALDINEY FARIAS DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e 16, “caput”, da Lei nº 10.826/2003, porque em 22.9.2016, por volta das 11 horas, na Rua Peixoto Werneck, 627, Artur Alvim, São Paulo, tinha em depósito e guardava drogas para fins de tráfico, com peso líquido de 1.151,7 g mais 220,7 g de cocaína e 445,9 g mais 8.523,7g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como possuía em depósito e ocultava arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na data dos fatos, Policiais Civis realizavam diligências pelo local dos fatos após denúncia anônima de drogas armazenadas e por isto ficaram “em campana”, de forma que avistaram o réu sair do imóvel e permanecer do lado de fora, observando a movimentação, atraindo assim, a atenção dos policiais. Em seguida, abordaram Waldiney e entraram na residência, encontrando em um local enterrado um barril plástico contendo 9 (nove) tijolos e pequenas porções de maconha, diversos unitários de cocaína, um fuzil de marca Tapco USA de calibre 762; 20 (vinte) munições de fuzil calibre 762; 5 (cinco) carregadores de marca PMAG e 365 (trezentos e sessenta e cinco) munições também de fuzil, de calibre 556. Posteriormente, foram encontradas mais quantidades de maconha, cocaína, e também um colete balístico e cadernos manuscritos.

A denúncia foi recebida inicialmente em 26.2.2016 (fls. 124/125), o réu foi citado (fls. 154), oferecida defesa prévia (fls. 140/147), com continuidade do feito (fls. 174), instrução, interrogatórios e debates.

O Ministério Público pediu a condenação, pois comprovados os fatos atribuídos ao réu, tendo ele reincidência, com regime inicial fechado (fls. 238/240).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O réu, por douta Defesa, pleiteou a liberação de bem, no mais, a absolvição, pela ausência de provas ou insuficiência delas, alternadamente, pena mínima, com recurso livre (fls. 241/264).

É o relatório.

D E C I D O

Quanto à preliminar, manifeste-se a Acusação.

A ação é procedente.

A *materialidade do delito* foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante delito de fls. 6/12, boletim de ocorrência de fls. 14/19, auto de exibição e apreensão de fls. 21/23, laudo de constatação 56/57, laudos de fls. 183/188, 189/194, 195/198 e 199/204, cocaína, maconha, arma e munições foram apreendidas.

A *autoria* é atribuível ao réu.

No distrito, ficou em silêncio, fls. 12, respaldado em norma de ordem constitucional, o que, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem é inocente. Se essa fosse a situação dos acusados, aproveitariam a primeira oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinham com o crime (cf. Apel. nº 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11ª Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.

Ailson, policial civil, prendeu o réu. Houve denúncia anônima via telefone, sendo feita campana. Ficaram 1 hora na campana. Estava com um colega e o Delegado. Ele, réu, apareceu no portão, houve identificação e declinaram motivo da presença. Feita revista pessoal, havia celular. Morava no local sozinho. Na sala, encima da mesa, havia cigarro de maconha, disse


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ser usuário. Do lado externo foi permitida revista. Alguns moradores guardam carros em um corredor. Nos fundos da casa, parte fofa, mato seco encima. Ele comentou sobre droga e armamento. Foi tirando pacotes e munições. 900 munições de fuzil e um fuzil. Pacotes, tabletes de droga, para venda. Pediram reforço, no forro havia boa quantidade de droga. Na casa, encima da cama, colete a prova de bala. Ele disse guardar a droga, fazia movimento do tráfico. Tinha anotações de nomes ou contabilidade. Não foi perguntado se trabalhava sozinho ou com alguém. Não conhecia ele de outra ocorrência. Partes de local em comodato. Pessoas da guarda de carro teriam acesso ao local do encontro da droga. Na hora da abordagem, poucas pessoas. Com a prisão, houve tumulto. Acha que outros civis, fora o réu não foram levados. Da entrada da comunidade, há local conhecido como ponto de tráfico. O próprio réu disse estar lá em comodato. Conversou com uma moça, que ratificou a informação, ela não foi conduzida à delegacia. Só havia policiais quando da confissão.

Emerson, policial civil, prendeu o réu. Existia investigação. Houve denúncia anônima via telefone, sendo feita campana. Ficaram 40, 50 ou 1:30 hora na campana. Estava com um colega e o Delegado. Ele, réu, apareceu no portão, houve identificação e declinaram motivo da presença. Feita revista pessoa, havia celular. Morava, aparentemente, no local sozinho. Dentro da geladeira porção pequena, disse ser usuário. Do lado externo foi permitida revista. Alguns moradores guardam carros em um corredor. Nos fundos da casa, parte fofa, mato seco encima. Depois comentou sobre droga e armamento. Foi tirando pacotes e munições. 400 ou 500 munições de fuzil e um fuzil. 13 ou 11 quilos, maconha e cocaína. Pediram reforço, no forro havia boa quantidade de droga. Na casa, debaixo da cama, capa do colete. Ele disse que havia droga, não comentou sobre movimento do tráfico tráfico. Não viu anotações de nomes ou contabilidade. Não incriminou outrem. Não conhecia ele de outra ocorrência. Na hora da abordagem, poucas pessoas. Com a prisão, houve tumulto. O réu foi levado sozinho. Da entrada da comunidade, há local conhecido como ponto de tráfico. Não sabe se o réu estava em comodato lá. Não conversou com uma moça, ela não foi conduzida à delegacia. Só havia policiais quando da confissão. Morava lá.

Os policiais ofereceram depoimentos consistentes e harmônicos entre si, incriminando o réu quanto a estar realizando tráfico, ter armamento pesado e munições.

Não há motivo para rechaçar os testemunhos, inexistente qualquer indício de que os policiais desejem incriminar gratuitamente o acusado. Eles foram compromissados para dizerem a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

verdade e, em caso contrário, cometeriam o crime de falso testemunho.

Se ele morava lá ou alugava o lugar é indiferente, pois indicou onde estava a droga, o armamento e munições.

Muitas vezes se verifica a menção dos policiais desejarem prejudicar alguém que tenha antecedentes criminal, tal qual o réu, porém, atribuir uma quantidade grande de droga e muitas munições não seria razoável. O ato seria desproporcional à atitude incriminatória.

Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. **Supremo Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus nº 74.251/SP** – São Paulo, 1ª Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e **Habeas Corpus nº 73.518/SP** – São Paulo, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. **Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus nº 98766/SP**, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; **Habeas Corpus nº 130537/RJ**, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; **Habeas Corpus nº 115510/SP**, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; **Habeas Corpus nº 38489/RJ**, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e **Habeas Corpus nº 28417/SP**, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação nº 990.09.025057-7**, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Borges Pereira, Julg. 01.12.2009; **Apelação nº 990.09.150746-6**, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ribeiro dos Santos, Julg. 01.12.2009; **Apelação nº 990.09.056197-1**, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; **Apelações ns. 993.04.076694-0 e 990.09.047692-3**, 13ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Lopes da Silva e Des. Cardoso Perpétuo, J. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.200330-5**, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, Julg. 11.11.2009; **Apelação nº 990.09.174019-5**, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Oliveira Passos, Julg. 11.11.2009; **Apelação nº 993.08.007218-3**, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. David Haddad, Julg. 12.11.2009; **Apelações ns. 990.09.173798-4 e 990.09.184274-5**, 9ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, na sequência, os Des. Penteado Navarro e Des. Galvão Bruno, Julg. 12.11.2009 e 29.10.2009; **Apelação nº 990.09.130107-8**, 8ª Câmara de Direito


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Criminal, Rel. Des. Encinas Manfré, Julg. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.203175-9**, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sydney de Oliveira Jr., Julg. 12.11.2009; **Apelações ns. 993.08.044297-5 e 993.05.075368-9**, 6ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Machado de Andrade e Des. José Raul Gavião de Almeida, Julg. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.203944-0**, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juvenal Duarte, Julg. 03.12.2009; **Apelações ns. 990.08.051988-3 e 993.05.002085-1**, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Augusto Siqueira e Des. William Campos, Julg. em 17.11.2009 e 24.11.2009; **Apelação nº 990.09.006709-8**, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Julg. 24.11.2009; **Apelação nº 990.08.123484-0**, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, Julg. 26.10.2009; **Apelação nº 990.09.219512-3**, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, Julg. 30.11.2009, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.

Valdecio conhece o réu, seu irmão. Não viu a prisão. Ele não morava na casa onde estava. Guarda um carro. O veículo é da irmã, Vânia. O veículo é um Scort. Ele foi guardar o carro lá. Não usa droga. Não faz tráfico. Nunca o viu com arma ou munição. Mora perto do local onde o réu guarda o carro. 10 pessoas guardam o veículo lá. Lá não mora ninguém. O quintal é usado. Estacionam lá, sendo a moça da esquina a dona, Priscila. Mora em outro lugar, com os irmãos. Ele trabalha, com pavimentação. Soube da prisão pois ligou ao réu. A distância até o local dos fatos da sua casa é 50 metros. Tinha 38 ou 40 pessoas no local. Havia estabelecimento comercial aberto. O apelido de seu irmão, réu, é "Mancha".

Leonilda é vizinha do réu. Conhece-o há muito tempo. Não viu quando preso. Soube depois. Ele não mora no local da prisão. Não sabe o que faz lá. Nunca ouviu falar que ele fazia uso de drogas ou tráfico. Nunca soube dele usar cartuchos ou arma de fogo. O réu mora com dois irmãos. Não é muito longe local de prisão e local de moradia. Sua irmã, Vera, disse que ele guardava carro lá. Não sabe de quem. Mora perto do lugar da detenção. O apelido do réu é "Mancha". Ouve falar de tráfico na região. Sua irmã disse que o réu já esteve preso, não sabe o motivo.

Apenas pessoas próximas, em vão, tentam eximir o réu de responsabilidade, todavia, não são presenciais. Seus depoimentos não têm força para afastar o dito pelos policiais civis.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em seu interrogatório, o réu declarou ter 47 anos de idade. Tem antecedentes (porte de arma). Não fazia tráfico. Não estava com cartuchos, fuzil ou colete. De manhã fez cirurgia, vinha do hospital, passou em casa, pegou o carro para guardar. Quando fechou o portão, ia entra para os fundos, viu os policiais na casa. Comentou não morar lá. Disse ter passagem. Perguntaram sobre "Bicudo", falou que não sabia. Pediu para chamar a dona da casa e o dono da bomboniere. Foi guardar um Scort, de sua irmã, Vania. Não viu algo. Ficou sentado de costas. Tinha 4 ou 5 carros. Falou que todos tinham acesso. Fez o contrato de locação com Priscila. A irmã de Priscila vende roupa e ela ajuda. Nunca viu os policiais civis. Falou a eles que só guardava o carro lá. Priscila foi até lá.

O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003, além de ser meio de defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O *interrogatório* é tanto *meio de prova* como de *defesa*, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de *meio de defesa* e de *prova*, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (*Curso completo de processo penal*. 5ª ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).

A versão é frágil, inverossímil e dissociada do conjunto probatório.

Em suma, o silêncio extrajudicial, a negativa infundada, depoimentos dos policiais civis, apreensão e laudos técnicos provam a realização do tráfico e porte de arma e munições não permitidos.

Doso as penas.

1ª fase

Considerando a diretriz do art. 59 do Código Penal, os antecedentes do réu, o resultado e consequências dos crimes, anormais se comparados a casos análogos, pois grande a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

quantidade de droga apreendida (1 saco de cocaína, 203 papélotes de maconha, 239 trouxinhas de cocaína e 9 tijolos de maconha) – podendo prejudicar muitos usuários, viciados e causas transtornos para colegas, amigos e familiares, com aflição social imensa, munições e arma de alta poder vulnerante (1 fuzil, com 20 cartuchos íntegros, 365 cartuchos íntegros para calibre 556 e 5 carregadores de plásticos) com o réu, o grau de culpa, intenso, com desejo de lucro fácil e com instrumento para proteger o comércio espúrio, além da possibilidade, efetiva de ferir e causar a morte de pessoas, com perigo concreto, pela notícia na mídia de várias reações com armas de policiais e quem está sendo preso, fixo as penas-base 2/3 acima do mínimo, ou seja, oito (8) anos e quatro (4) meses de reclusão e oitocentos e trinta e três (833) dias-multa para o tráfico e cinco (5) anos de reclusão e dezesseis (16) dias-multa para o porte de armamento e munições.

2ª fase

Não há circunstâncias atenuantes.

O réu é reincidente, fls. 137/138, logo, acresço às penas 1/6, tendo-se nove (9) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e novecentos e setenta e um (971) dias-multa para o tráfico e cinco (5) ano e dez (10) meses de reclusão e dezoito (18) dias-multa para o porte de armamento e munições.

Inexistem outras agravantes.

3ª fase

O réu, conforme dito, não é primário e tem maus antecedentes, dedica-se às atividades criminosas e há prova de se integrar a organização criminosa, pela maneira de organização dessa maneira, quantidade de droga, arma e munições, portanto, não incide o disposto no art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Não há causas de diminuição e de aumento.

Pena final


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica, totalizando: quinze (15) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e novecentos e oitenta e nove (989) dias-multa.

Regime de pena

O regime da pena privativa da liberdade deve ser inicial fechado.

Segundo a nova redação do art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/1990, em conformidade à Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007: “A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”.

O acusado praticou delito grave, tráfico de entorpecentes, combatido em escala mundial, pelas consequências danosas que causa à sociedade, primordialmente quando a quantidade não é desprezível, ao contrário, volumosa. Acrescente-se que esta com fuzi, com alto poder vulnerante, e farta munição.

Cabe invocar ensinamento do STF: “**A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.**” (HC nº 70.289-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).

Ora, é de pronta inteligência que a perpetração de tráfico, com arma e munições, denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.

Conforme ensina Julio Fabbrini Mirabete: “A pena de prisão teve sua origem nos mosteiros da Idade Média, “como punição imposta aos monges ou clérigos faltosos, fazendo com que se recolhessem às suas celas para se dedicarem, em silêncio, à meditação e se arrependessem da falta cometida, reconciliando-se assim com Deus” (Manoel Pedro Pimentel. *O crime e a pena na atualidade*. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 134). Essa idéia inspirou a construção da primeira prisão destinada ao recolhimento de criminosos, a *House of Correction*,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

construída em Londres em 1550 e 1552, difundindo-se de modo marcante no Século XVIII” (*Manual de direito penal*. 2ª ed. São Paulo, Atlas, 1986, p. 246-247).

Na mesma obra, lembra: “Se do ponto de vista educativo e recuperatório a pena de prisão apresenta tais aspectos negativos, não se pode, entretanto, questionar que continua ela a ser o único recurso aplicável para os delinquentes de alta periculosidade. Mesmo Foucault, acerbo crítico do sistema prisional, reconhece que nessa hipótese não há possibilidade de mudança, sendo a pena de prisão detestável solução de que não se pode abrir mão. E Manoel Pedro Pimentel lucidamente afirma: “A prisão precisa ser mantida, para servir como recolhimento inicial dos condenados que não tenham condições de serem tratados em liberdade” (Ob. cit., p. 185-186). A prisão, deve-se reconhecer é insuprimível, quer como instrução de repressão, quer como defesa social” (p. 249).

Se, mais além e com efetividade, se almeja observar o princípio de individualização das penas, é preciso, como fez ver Karl Mannheim, que o juiz proceda “em relação ao delincente individual como o legislador faz em relação aos delinquentes em abstrato” (*Criminologia Comparada*, tradução portuguesa de J. F. Faria Costa e M. Costa Andrade, ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1984, vol I, p. 216).

O que deve ser levado em conta para a fixação do regime não é o crime em sua dimensão abstrata – vale dizer, a gravidade hipotética de um delito – e sequer exclusivamente em sua posição concreta pretérita, até porque a só gravidade jurídica da pena de um crime “carece freqüentemente de significação desfavorável para o prognóstico” (Middendorff, remetendo-se a lições de Mannheim, Bockelmanne e dos Glueck. *Teoria y Práctica de la Prognosis Criminal*. Madrid, Ed. Espasa – Calpe, 1970, 128).

Jescheck diz que para dosar a pena deve-se levar em conta “crescente aumento de determinadas classes de delito em algum setor concreto (prevenção geral)” (*Tratado de derecho penal*. Tradução castelhana de Mir Puig e Muñoz Conde, Ed. Bosch, Barcelona, 1981, vol II, parágrafo 82, III, n. 2.).

A benevolência infundada – a que se referiu graficamente Jescheck (Op. cit., vol I, parágrafo 1, I, n. 2) -, ou, na dura expressão de Exner “as fraquezas do juiz, que deixam indefesa a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sociedade" (*apud* Middendorff. Op. cit., p. 168), terminam por adquirir um influxo propiciador não só da recidiva do condenado – frustrando a meta de prevenção específica – mas também do contágio hierárquico – reduzindo a eficácia da prevenção genérica.

Dessa forma, repreende-se a conduta do réu, previne-se que não mais a cometa, tampouco outros crimes, e procure se ressocializar.

“Cícero, no "De Officiis", I, 58, dizia que o homem não pode ficar sozinho e, permanentemente procura companhia para falar e ouvir, ensinar e aprender, mesmo que, com uma espécie de varinha mágica, *quasi vírgula divina*, pudesse obter tudo o que quisesse, o homem é sócio do homem. Platão, na "República", II, 369, diz que a vida urbana é exposta como causada pela necessidade. Aristóteles, "Política", I, ao contrário, salienta que "animal político", *politikon zoon*, está para significar que o modo ideal de existência humana consiste em viver na *polis*, ou cidade-estado” (Antonio Junqueira de Azevedo. “Ciência do Direito, Negócio Jurídico e Ideologia”. *Estudos em homenagem ao professor Silvio Rodrigues*. São Paulo, Editora Saraiva, 1989, p. 18-19.)

Pode o juiz determinar o cumprimento da pena em regime fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2º, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6ª T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).

Além disso, o tráfico é equiparado ao delito hediondo, assim, incidia o então art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, que previa o regime integral fechado, dispositivo constitucional, segundo parcela considerável da jurisprudência (apenas para exemplificar vide RT 735/581, 724/577; RSTJ 76/268; JTJ 179/304; dentre outros julgados).

Dessa maneira, não é apropriado substituir a pena privativa da liberdade por pena restritiva de direitos. Em caso contrário, ficaria com sentimento de impunidade em seu espírito, dificultando a apreensão da extensão da atitude ilícita.

Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.

Valor do dia-multa

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela precariedade econômica do réu (art. 43, "caput", da Lei nº 11.343/2006, e art. 49, parágrafo 1º, do Código Penal), com atualização prevista no art. 49, parágrafo 2º, do Código Penal (*"A atualização da pena de multa assegura a permanente manutenção do montante, sem qualquer alteração do mesmo, até o efetivo pagamento, sob pena de, dada as intempéries que assolam o nosso País, o exigível nada representar"* (RT 683/327) e *"A atualização monetária da pena de multa é a grande inovação da Reforma Penal de 1984 e não pode ser abolida por decretos-lei que visam a organizar a economia do País. O parágrafo 2º do art. 49 do CP, que sobre ela dispõe, tem caráter de norma penal em branco. A mudança dos índices de atualização monetária (norma complementar) em nada altera a essência da lei"* (RT 636/312).

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, CONDENANDO o réu **WALDINEY FARIAS DA COSTA**, qualificado nos autos, à pena de **quinze (15) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias** de reclusão, **com regime inicial fechado**, e pagamento de **novecentos e oitenta e nove (989) dias-multa**, como incurso no **art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, "caput", da Lei nº 10.826/2003 c/c o art. 61, inciso I, do Código Penal**.

O acusado não poderá recorrer em liberdade, pois fixado o regime inicial fechado, ficou preso durante a instrução, é reincidente e sua periculosidade não é desprezível. Nunca é demais lembrar que "A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

constitucional da presunção de inocência” (Súmula nº 9 do ESTJ). **“O STF tem decidido que o disposto no item LVII, do art. 5º da CF de 1988, ao dizer que 'ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória', não revogou os dispositivos do CPP que prevêm a prisão processual”** (RJTJERGS 148/15). **“O art. 5º, LVII, da Constituição não alterou o art. 594 do CPP, segundo entendimento consagrado na Súmula 9 do STJ”** (RT 686/391). No mesmo sentido, RT 728/476, JSTJ 19/217 e 42/86-7. Além disso, vide art. 59 da Lei nº 11.343/2006.

Recomende-se na prisão.

Nome no rol, oportunamente.

Não há prejuízo mensurável do crime, logo, descabe a fixação de algum valor para reparação de dano, conforme o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008.

Oficie-se para destruição da bolsa, das 3 caixas de munição vazia, diversas tampas, diversos eppendorfs de cor amarela, cadernos de papelaria (2), bacia, arma e munições periciadas e drogas (fls. 21/23).

Quanto aos celulares, 2, oficie-se para destruição e, se houver valor econômico, para leilão (22).

Dê-se vista dos autos à Acusação, para se manifestar sobre a preliminar.

Custas de 100 UFESPs pelo réu.

P. R. I. e C.

São Paulo, 27 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**